

1500277-76.2022.8.26.0581

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2063030/2022 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 23435310 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 341/22/211 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 2063030 - DEL.POL.SÃO MANUEL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUÍS OTÁVIO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

1ª Vara

Rua Ettore Targa, s/nº, São Manuel-SP - cep 18650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500277-76.2022.8.26.0581 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500277-76.2022.8.26.0581

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2063030/2022 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 23435310 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 341/22/211 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 2063030 - DEL.POL.SÃO MANUEL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUÍS OTÁVIO PALOMBARINI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou LUÍS OTÁVIO PALOMBARINI, já qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (LD), porque, no dia 07 de março de 2022, por volta das 14h00min, na Avenida São Manuel, nº 100 - Cohab I, nesta cidade e Comarca de São Manuel, o réu supostamente mantinha depósito 80 (oitenta) pinos, contendo cocaína, com peso líquido total de 18,56 gramas, substância que causa dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas,

além de mais 72 (setenta e dois) outros microtubos vazios, utilizados para embalar os entorpecentes.

Ainda segundo a exordial acusatória, policiais civis cumpriam mandado de prisão preventiva contra o denunciado, em razão da prática de crime de roubo majorado. Assim que chegaram ao local, realizaram busca pessoal no réu, mas nada de ilícito foi com ele encontrado. Ato contínuo, diante de fundadas suspeitas, os policiais ingressaram no imóvel, onde lograram êxito em encontrar, sobre a cama do denunciado, oitenta pinos plásticos, contendo cocaína, prontos para a venda imediata, bem como outros setenta e dois microtubos vazios, idênticos aos cheios. O réu foi preso em flagrante (fl. 04).

Em audiência de custódia (fls.46/48), homologada a prisão em flagrante, foi convertida em preventiva.

Mandado de prisão cumprido às fls. 63/65.

Notificado à fl. 99, o réu apresentou defesa prévia às fls. 82/85.

Recebida a denúncia em 22/03/2022, ocasião em que designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual (fl. 86).

Em audiência de instrução e julgamento (fls...) foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, a d. representante do Ministério Público pugna pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia.

A d. defesa, por seu turno, requer a absolvição do réu; subsidiariamente, postula a desclassificação para o crime do art. 28 da LD.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

Nesse passo, anoto que a materialidade dos delitos restou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl. 04); termos de depoimentos (fls.05/06); interrogatório do acusado na fase policial (fls. 07/08); auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); boletim de ocorrência n.º 341/2022 (fls. 12/13); laudo pericial toxicológico provisório (fls. 17/22) e definitivo (fls. 109-111 e 112-114); laudo pericial (fls. 104/106); relatório final do inquérito policial (fl. 121/122); bem como a prova oral colhida.

Sobreleva notar que a substância apreendida (cocaína) se encontra expressamente prevista na Portaria n.º 344/98 e Resolução n.º 104 da Anvisa, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (art. 1º, §1º, da LD).

Da mesma forma, entendo comprovada a autoria dos fatos, porquanto os elementos produzidos durante o inquérito policial estão em plena consonância àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em sede judicial.

A testemunha Marcelo Alexandre Ribeiro Ferreira, policial civil, declarou que estava na posse de um mandado de prisão preventiva contra o réu, que estava em frente de sua casa. Que o réu autorizou os policiais a entrar em sua casa, momento em que foram encontrados 80 pinos de cocaína no quarto do réu. Que o réu disse que a droga era para consumo próprio. Que já efetuou a prisão do réu quando ele. Igualmente, a testemunha Rogério Aparecido Guiari, também policial civil, aduziu que estava dando cumprimento a um mandado de busca e apreensão na casa do réu, momento em que foi perguntado se havia alguma coisa de errada em sua casa, sendo que houve resposta afirmativa. Informou que encontrou pinos de cocaína no interior da residência devidamente embalados para o tráfico. Sustentou que o réu afirmou que a droga era para consumo próprio. Disse que haver denúncias de que o réu estava traficando na Cohab I e Cohab II e que a quantidade de drogas apreendidas com o réu é expressiva para a região. Que o réu não resistiu à prisão.

O réu, em juízo, disse que estava na frente de casa junto com sua mãe e sua irmã quando chegaram policiais civis para lhe prender. Que foi algemado pelos policiais e que autorizou a entrada dos policiais em sua residência e informou que possuía droga para seu consumo no seu quarto. Que após localizarem as drogas os policiais levaram o réu para a delegacia. Que está buscando se recolocar no mercado de trabalho. Que na época trabalhava e que adquiriu a substância ilícita com o dinheiro que auferia. Que possui uma filha de três anos de idade que mora com a sua

mãe.

Cumpra dizer que o depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais. A circunstância de serem agentes públicos não os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e genérico sobre o depoimento, de sorte a reduzir-lhe, "a priori", o poder de convencimento.

Com efeito: "São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha." (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 07/03/2017, DJe de 14/03/2017).

Consoante se infere dos depoimentos colhidos, não pairam dúvidas de que o réu praticou o delito em voga, basta ver a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas em seu poder, previamente embaladas para a venda a terceiros e em tamanhos diversos, tudo a revelar o intuito de comercialização. A condenação pelo tráfico de drogas não reclama a identificação do fornecedor ou do comprador, nem mesmo se exige a prova da efetiva ocorrência do ato de mercancia, tratando-se de tipo misto alternativo, cuja conduta do réu se ajustou à modalidade "trazer consigo".

O delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado dolo específico, pois este "aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direito especialmente previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita" (VICENTE GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13ª edição, págs. 150/151). O crime de tráfico de drogas, tal como concebido na legislação brasileira, não pressupõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização (STF, HC nº 69.806, rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp nº 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer). Consoante já se decidiu, "a apreensão de grande quantidade de drogas configura o animus de traficar, somente ilidível quando alegada a finalidade exclusiva de uso próprio, com robusto material probatório favorável ao mesmo" (STJ, Rec. Esp. nº 163.640, rel. Min. Jorge Scartezzini, apud Alberto Silva Franco e outros, Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7ª edição, pág. 3190).

Nessa perspectiva, podemos acrescentar a jurisprudência do STJ: "Indicando a Corte local dar-se a condenação não apenas pelo depoimento de policial, mas por outras provas também valoradas, não cabe a pretensão de nulidade da condenação.

Inexistindo impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade. 3. Agravo regimental improvido" (AgRg nos EDcl no HC 446151/RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 07/02/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 27/02/2019).

Conclui-se, portanto, que pelas circunstâncias da apreensão e pela maneira como estavam embaladas as substâncias entorpecentes se prestavam ao comércio ilícito. Por fim, ressalto que a versão apresentada pelo réu restou isolada nos autos, uma vez a quantidade de drogas, a forma como estavam embaladas e o perfil econômico apresentado pelo acusado não apontam no sentido de serem as drogas exclusivamente utilizadas para o consumo próprio do réu, logo pelo contrário, tais circunstâncias evidenciam a traficância.

Assim, autoria e materialidade comprovadas, passo à dosimetria da pena, atento ao sistema trifásico previsto pelo artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, a culpabilidade do réu, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, não é acentuada a ponto de merecer exasperação da pena-base; a ré não registra maus antecedentes, pois não possui condenações com trânsito em julgado, conforme se observa da folha de antecedentes das fls. 31-32 (Súmula 444, STJ); não há registros nos autos quanto a conduta social e a personalidade do agente; motivos normais ao tipo; o delito foi praticado em circunstâncias normais ao tipo; a conduta social não foi apurada nos autos; as consequências do delito são inerentes

ao tipo penal; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do tipo penal.

Atento aos requisitos do art. 42 da Lei 11.343/06, observo que, em que pese a natureza das drogas apreendidas (cocaína), entendo que a quantidade de drogas (menos de 20g) não permite a exasperação da pena. Fixo a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, em que pese a presença da atenuante da menoridade relativa, deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, cabível no caso vertente a aplicação do disposto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, pois, ao instituir o parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, o escopo do legislador foi de beneficiar o agente que pela primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja conduta não representa um maior perigo para a coletividade, de modo que a pena reduzida é suficiente para a ressocialização e reprova suficientemente o comportamento, o que se ajusta ao caso vertente.

No caso dos autos, o réu é primário, de bons antecedentes, não havendo qualquer indício de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, razão pela qual reconheço o privilégio, forte na lei e na jurisprudência do TJ-SP. Contudo, considerando que o réu possui passagens por ato infracional análogo ao tráfico de drogas quando adolescente, fato que, no entender deste Juízo não afasta o privilégio, mas permite que o redutor do § 4º da Lei de Drogas seja aplicado em patamar inferior ao máximo, reduzo a pena de metade, tornando-a definitiva em 2 anos e 5 meses de reclusão e 250 dias-dias multa, estabelecido o dia-multa no valor unitário mínimo.

Regime inicial de cumprimento da pena (art. 33, CP)

Fixo o regime inicial aberto, tendo em vista o montante de pena aplicada, estando ausentes os efeitos da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Do Direito de Recorrer em Liberdade/Prisão Preventiva (artigo 387, §1º, do CPP)

O réu responde ao processo preso desde a data dos fatos, sendo que o regime aberto é incompatível com a prisão preventiva, visto que a reprimenda aplicada nesta sentença é mais benéfica que a prisão cautelar determinada na decisão das fls. 46-48.

Nesse sentido, o TJ-SP:

"Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente preso preventivamente durante todo o processo e que acabou sendo condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, vedado o direito de recorrer em liberdade sob a alegação de ainda estarem presentes os requisitos da custódia cautelar. Decisão do juízo a quo que não foi capaz de apresentar justificativas adequadas para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Isto porque, uma vez estabelecido na condenação que o regime de início de cumprimento de pena será o semiaberto, torna-se incompatível e desproporcional, manter o paciente segregado cautelarmente até o trânsito em julgado, mesmo sob a alegação de que ainda estão presentes os fundamentos ensejadores da prisão preventiva. Respeito à proporcionalidade. Ordem concedida com imposição de medidas cautelares." (TJ-SP - HC: 20378927420218260000 SP 2037892-74.2021.8.26.0000, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 19/03/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/03/2021)

Dessa forma, revogo a prisão cautelar e concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, desde que cumpridos as seguintes condições: a) proibição de frequentar bares, boates ou qualquer outro estabelecimento de má reputação; b) proibição de ausentar-se da Comarca onde residem por lapso superior a 08(oito) dias, sem autorização do Juízo; c) recolher-se em seu domicílio das 22:00 às 06:00 da manhã, exceto se estiverem trabalhando; d) comparecimento pessoal e obrigatório a Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades e, ainda, comunicar o Juízo, qualquer mudança de endereço que ocorra.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR LUÍS OTÁVIO PALOMBARINI, já qualificado, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 2 anos e 5 meses de reclusão e 250 dias-dias multa, estabelecido o dia-multa no valor unitário

mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Revogo a prisão cautelar, nos termos da fundamentação.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora concedo ao acusado por ser assistido pelo Convênio DPE-OAB.

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD).

Como a quantia apreendida está intrinsecamente vinculada à prática delitiva – produtos da mercancia da droga –, declaro seu perdimento em favor da União, devendo ser transferida para o FUNAD (art. 91, II, do CP).

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;

b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;

c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;

d) expeça-se guia de execução definitiva.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se.

Intimem-se.

São Manuel, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA